

<제2편 소송의 주체.제3장 법원.제2절 법관의 제척·기피·회피>

I. 법관의 제척

1. 의의

- 법관의 제척이란 법관이 구체적인 사건과 특수한 관계가 있는 경우에 법률에 의하여 당연히 그 사건의 직무집행에서 배제되는 제도를 의미한다. 이는 재판의 공정성에 대한 외관상의 의심을 사전에 차단하고 당사자의 신뢰를 확보하기 위한 강행규정적 성격을 가진다. 제척 사유가 존재하면 별도의 재판이나 신청 없이도 해당 법관은 법률상 당연히 직무수행 권한을 상실한다.

2. 제척이유[민소법 제41조]

- 민사소송법 제41조는 법관이 직무집행에서 제척되는 사유를 한정적으로 열거하고 있다. 첫째, 법관 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 사건의 당사자가 되거나 당사자와 공동권리자·공동의무자의 관계에 있는 경우이다. 둘째, 법관이 당사자와 친족관계에 있거나 있었던 경우이다. 셋째, 법관이 사건에 관하여 증언이나 감정을 한 경우이다. 넷째, 법관이 사건의 당사자의 대리인이었거나 대리인이 된 경우이다. 다섯째, 법관이 불복 사건의 이전 심급의 재판에 관여한 경우이다. 이는 선입견을 배제하고 심급 제도의 실효성을 보장하기 위함이다.

3. 제척효과

- 제척 사유가 있는 법관은 당해 사건에 관한 모든 직무집행을 할 수 없다. 여기에는 변론의 진행, 증거조사, 판결의 선고뿐만 아니라 종국판결 이전의 부수적 결정도 포함된다. 제척된 법관이 재판에 관여하여 내린 판결은 절차상 중대한 하자가 있는 것으로 간주된다. 다만, 제척 결정이 확정되기 전에 한 소송행위라도 후에 제척 결정이 나면 소급하여 효력을 잃는 것이 원칙이나, 긴급을 요하는 행위나 종국판결의 선고 등 예외적인 경우에는 효력이 유지되기도 한다.

4. 관련판례

- 판례는 제척 사유 중 이전 심급의 재판에 관여한 때의 범위를 엄격하게 해석한다. 최종변론과 판결의 합의에 관여하거나 종국판결과 더불어 상급심의 판단을 받는 중간적인 재판에 관여함을 말하는 것이고, 최종변론 전의 변론이나 증거조사 또는 기일지정과 같은 소송지휘상의 재판 등에 관여한 경우는 포함되지 않는다.

II. 법관의 기피

1. 의의

- 법관의 기피란 법관에게 법정 제척 사유는 없으나 재판의 공정성을 기대하기 어려운 객관적 사정이 있는 경우, 당사자의 신청에 의하여 법관을 직무집행에서 배제시키는 제도를 말한다. 제척이 법률에 의한 당연 배제라면, 기피는 당사자의 형성적 권리 행사에 의한 재판상 배제라는 점에서 차이가 있다.

2. 기피이유

- 기피 사유는 법관에게 재판의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 때이다. 이는 통상적인 법관의 입장에서 당사자와의 친분 관계, 원한 관계, 특정 이해관계 등으로 인해 편파적인 재판을 할 염려가 있다고 객관적으로 인정될 만한 사유를 의미한다. 단순히 법관의 재판 진행 방식에 불만을 갖거나 법률 해석에 대한 견해 차이가 있다는 이유만으로는 기피신청이 정당화되지 않는다.

3. 기피절차

- 기피신청은 해당 법관이 소속된 법원에 서면으로 신청하여야 한다. 신청인인 당사자는 신청한 날부터 3일 이내에 기피 사유를 서면으로 소명하여야 한다. 기피신청을 받은 법관은 이에 대한 의견서를 제출하여야 하며, 해당 법관의 소속 법원 합의부에서 기피신청의 수용 여부를 결정한다. 다만, 소송의 지연을 목적으로 함이 명백하거나 신청 방식에 어긋나는 경우에는 해당 법관 또는 재판부가 직접 신청을 각하할 수 있다.

4. 기피신청의 효과

- 기피신청이 제기되면 원칙적으로 소송절차는 정지된다. 이는 불공정한 재판이 진행되는 것을 막기 위한 당연한 조치이다. 절차 정지의 예외로는 종국판결의 선고나 긴급을 요하는 행위가 있다. 만약 절차 정지 규정을 위반하여 소송을 진행하고 판결을 내렸다면, 이는 상소 사유가 된다. 기피신청이 각하되거나 기각된 경우에는 즉시항고를 통해 불복할 수 있으나, 이 경우에도 소송절차는 정지되지 않는 것이 원칙이다.

5. 기피결정의 효과

- 기피신청이 이유 있다고 인정되어 기피결정이 확정되면, 해당 법관은 해당 사건의 직무집행에서 완전히 배제된다. 이후의 재판은 다른 법관에 의해 진행되어야 한다. 기피결정 이전에 해당 법관이 한 소송행위의 효력에 대해서는 견해의 대립이 있으나, 당사자가 이익을 제기하지 않는 한 유효한 것으로 취급되는 것이 일반적이다.

III. 법관의 회피

- 법관의 회피란 법관 스스로 자신에게 제척 또는 기피의 사유가 있다고 판단하는 경우, 자발적으로 해당 사건의 직무집행에서 물러나는 것을 말한다. 이는 법관의 양심과 직업윤리에 기초한 제도로서, 당사자의 신청 없이 법관이 소속 법원의 허가를 받아 결정한다. 회피의 사유는 제척이나 기피 사유와 동일하며, 회피 허가 결정이 내려지면 해당 법관은 사건에서 배제되고 새로운 법관이 지정된다.

IV. 결론

- 법관의 제척·기피·회피 제도는 법관은 공정하여야 할 뿐만 아니라 공정하게 보여야 한다는 법언을 실현하는 핵심 기제이다. 제척은 법정 사유를 통한 당연 배제를, 기피는 당사자의 신청을 통한 사후 배제를, 회피는 법관의 자발적 배제를 의미하며 상호 보완적으로 작동한다. 이러한 제도들은 법관 개인의 주관적 성실성을 넘어 시스템적으로 재판의 중립성을 담보한다. 다만, 기피신청이 소송 지연의 수단으로 악용되는 사례를 방지하기 위해 법원은 기피 사유를 엄격히 심사하고 남용적 신청에 대해서는 단호한 각하결정을 내려야 한다. 결국 이 제도들의 올바른 운용은 국민의 재판에 대한 신뢰를 높이고 사법 정의를 확립하는 초석이 된다 할 것이다.